

1501295-55.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... portando as munições para assegurar o sucesso do tráfico de drogas, de forma que não é possível reconhecer a conduta relacionada ao armamento como causa de aumento de pena da traficância.

Ao contrário, não há prova que as munições eram empregadas como meio para o tráfico, de forma que sua posse tem existência autônoma e desvinculada do tráfico das drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501295-55.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501295-55.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricamar Gomes Duarte Júnior

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Ricamar Gomes Duarte Júnior foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque por volta das 19h10min de 18 de setembro de 2021, no interior da residência situada na Rua Amadeo Rovida, nº 32, Bonfim, de Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava para fins de venda a terceiros consumidores, 7 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 3 gramas, 40 invólucros de maconha, com massa líquida de 21,3 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, além de manter sob sua posse 5 munições de calibre .38, de uso permitido, com capacidade de efetuar disparo.

Segundo consta na denúncia, visando a obter dinheiro de forma rápida e ilegal, o réu vinha deliberadamente praticando o crime de narcotráfico nesta cidade,

utilizando-se de sua residência para confecção das drogas em porções menores, que seriam destinadas à venda.

Na noite do dia dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando o avistaram em atitude suspeita em frente à sua casa, situada no endereço supramencionado, resolvendo abordá-lo.

Efetuada revista pessoal, foram encontrados em poder do réu 7 eppendorfs de cocaína, prontos para serem vendidos. Indagado a respeito se havia mais algo de ilícito, ele disse aos policiais que tinha mais drogas em sua residência.

Autorizada a entrada, os policiais encontraram dentro do armário da cozinha da residência do réu 40 invólucros de maconha, embalados individualmente, petrechos comumente usados para confecção em porções menores consistentes numa balança digital, dois rolos de filme de cozinha e aproximadamente 100 sacolés plásticos vazios, além da quantia de R\$ 110,00 em dinheiro, proveniente do tráfico.

Prosseguindo na vistoria, os policiais encontraram no quintal 5 munições intactas de calibre 38, de uso permitido.

Questionado a respeito das drogas encontradas, o réu confessou informalmente aos policiais que teriam cunho mercantil, razão pela qual recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida às fls. 83/85.

Citado (fls. 163), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 164/174.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, informantes e o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público defendeu a parcial procedência da ação penal. Enfatizou a narrativa fornecida pelos policiais. Sustentou que diversos petrechos comumente utilizados no fracionamento e embalagem das drogas foram localizados no imóvel. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Aduziu ser possível a redução da reprimenda em fração intermediária na terceira fase. Pugnou pela imposição de regime inicial semiaberto. Defendeu a aplicação do concurso material de crimes.

A Defesa pediu a absolvição do réu. Destacou a negativa de autoria fornecida pelo réu e a palavra das testemunhas de defesa. Sustentou que o acusado comprava drogas em quantidade suficiente para evitar retornar sempre à "biqueira". Destacou que o réu não foi algemado em momento algum, pois colaborou com os policiais. Pontuou que a balança e os sacolés são utilizadas pela esposa do réu, que comercializa doces no local. Subsidiariamente, pediu a redução da pena por tráfico em fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Argumentou que as munições foram encontradas na casa pelo réu. Defendeu que não deve ser reconhecida a prática de crime de posse de munição sem a correspondente arma de fogo. Requereu a restituição dos objetos apreendidos.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de tráfico de drogas e posse irregular de munição, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitivas estão alicerçadas em auto de prisão em

flagrante (fls. 1/2), termo de depoimento (fls. 3/4), termo de interrogatório (fls. 5), auto de qualificação (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo pericial (fls. 87/89 e 94/96) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha Richardson Alves de Alcântara informou que estava em patrulhamento pela região, conhecido ponto de tráfico. Aduziu que viu o réu saindo de sua casa, mas ele ficou nervoso, o que motivou a abordagem. Encontrou sete pinos de cocaína na posse do réu. Asseverou que o réu confessou que mantinha drogas em casa e permitiu o acesso dos policiais à sua casa. Informou que foram encontradas na cozinha 40 porções de maconha e petrechos para o tráfico. Na área de serviço, encontrou cinco munições. Disse que o réu confessou que venderia a drogas, pois precisava de dinheiro. Afirmou que o réu já conseguiu fugir de uma abordagem de sua equipe. A abordagem foi realizada ainda na calçada. Informou que o réu estava sozinho naquele momento. Não havia outras pessoas na casa, mas posteriormente chegaram familiares. Contou que não foi necessária a utilização de algemas, pois o réu colaborou com os policiais.

A testemunha Murilo Pacheco Vianna disse que estava em patrulhamento da Força Tática quando acessou a via dos fatos, conhecida pelo tráfico de drogas, especialmente por haver uma praça e uma quadra poliesportiva. Avistou um indivíduo saindo de uma residência. Em razão da dissimulação no comportamento do acusado, que tentou retornar para a casa imediatamente, os policiais realizaram a abordagem. Encontrou 7 pinos de cocaína com o réu. Questionado, o réu disse que aquela era sua casa, confirmou que mantinha outras drogas no local e permitiu o acesso da polícia. No local foram encontradas 40 buchas de maconha, balança de precisão, "sacólés" vazios, rolos de papel filme. Na área de serviço, encontrou cinco munições de calibre .38. Afirmou que o réu confessou a propriedade de todos os objetos e informou que venderia a drogas, pois precisava de dinheiro. Não conhecia o acusado. Disse que o réu estava sozinho quando saía de casa. Asseverou que o réu não disse que era usuário, mas que vendia drogas, pois precisava de dinheiro.

Aline, esposa do réu, informou que estava em casa no momento da revista efetuada pelos policiais. Asseverou que o réu indicou aos policiais onde estavam as porções de maconha, as quais eram destinadas ao seu consumo pessoal. Disse que ele costuma comprar grandes quantidades de drogas. Aduziu que vende doces informalmente. Informou que há uma placa em frente ao imóvel com publicidade dos doces vendidos, entre eles "geladinhos". Disse que o réu trabalha informalmente. Informou que outras duas crianças também moram no local. Relatou que o réu usa drogas há um tempo e costuma comprar maiores quantidades para não ter que voltar ao local da venda. Não sabe há quanto tempo a droga estava em casa.

Solange de Oliveira dos Santos Silva, amiga do réu, disse que frequenta a residência às vezes. Informou que estava no imóvel no momento da abordagem. Contou que toda a família do réu também estava no local no momento da abordagem. Não acompanhou as buscas no interior da casa. Disse que o réu saiu do imóvel sem o uso de algemas.

Amanda Lauriene Duarte Monteiro, irmã do réu, falou que estava em frente à sua casa na companhia do réu e da testemunha Solange quando a polícia chegou. Contou que o réu estava com a filha de 2 anos de idade no colo no momento da abordagem. Não acompanhou as buscas no interior da casa. Disse que o réu saiu do imóvel sem o uso de algemas. Asseverou que mora na casa ao lado do réu. Informou que estava conversando com Solange sobre algumas roupas.

Interrogado, o réu disse que estava em frente de casa esperando um amigo para trabalhar informalmente por três dias. Contou que a polícia se aproximou e efetuou a abordagem na frente de familiares e amigos. Aduziu que informou aos policiais que mantinha outras drogas em sua casa, que eram destinadas ao seu consumo pessoal.

Indicou o local onde estavam as drogas. Asseverou que a balança eram utilizada para produzir geladinhos por sua esposa. Aduziu que as munições estavam guardadas no forro da casa, mas não eram de sua propriedade. Afirmou que encontrou as munições no local e optou por não mexer, pois acreditava que pertencia ao proprietário da casa. Disse que costumava comprar maior quantidade de drogas para não precisar retornar sempre à "biqueira". Havia comprado R\$ 300,00 em maconha e cocaína poucos dias antes. Consome maconha desde a adolescência, mas passou a usar cocaína há pouco tempo. Informou que gravou um vídeo no qual disse que autorizava o acesso dos policiais ao imóvel, mas sua esposa ficou separada nesse momento.

Bem provadas a autoria e a materialidade, conforme dispõem o artigo 33, caput, da Lei de Drogas e o artigo 12, da Lei 10.826/03:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa."

Verifica-se que a conduta do réu se enquadra em ao menos dois dos verbos-núcleo do tipo, notadamente guardar e trazer consigo drogas para difusão a usuários, resultando, assim, configurada a traficância.

Por sua vez, em relação às munições, o verbo-núcleo do tipo penal imputado ao réu é manter sob sua guarda, conduta que foi comprovada em juízo pela prova testemunhal e documental, que corroborou integralmente os elementos colhidos durante a fase do inquérito.

A própria prisão em flagrante do réu deu conta de que estocava em sua casa 3 gramas de cocaína e 21,3 gramas de maconha (fls. 25/28), drogas que estavam divididas em pequenas porções, além de cinco munições de calibre nominal .38" (fls. 21/23).

Submetido à perícia técnica, resultou comprovado que as munições apresentavam potencialidade lesiva e estavam aptas e eficazes para a realização de disparos (fls. 154/157).

Em adição à prisão em flagrante, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo com fidelidade o quanto afirmado durante a fase do inquérito, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado, dizendo como se deu a prisão e as demais circunstâncias em que foram encontradas as drogas com o réu.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Por outro lado, a negativa de autoria escorada na palavra de familiares e de uma testemunha, vizinha e amiga pessoal do acusado, não causam abalo aos demais elementos de prova.

De forma isolada, a simples afirmação do réu de que costumava comprar drogas em grande quantidade nas biqueiras para que não precisasse voltar ao local com frequência não permite afastar a evidente prova da traficância.

Vale dizer que as porções de maconha estavam embaladas individualmente em pequenas porções, prontas para difusão aos usuários. Igualmente, a cocaína estava dividida em sete eppendorfs, os quais o acusado carregava consigo em plena via pública, o que corrobora a narrativa dos policiais de que, de fato, seriam destinados ao tráfico e não ao mero consumo pessoal.

Repisa-se que a quantidade de porções individuais e a natureza das drogas, atrelada à presença de balança de precisão e embalagens tipo "filme PVC" destinadas ao fracionamento em porções individuais dão conta da traficância exercida.

Quem é apanhado, como aqui, mantendo diversas pequenas porções de droga escondida e atrelada a utensílios sabidos por se destinarem ao fracionamento e embalagem individual de entorpecentes, não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância.

Impõe-se, agora, reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Verifico, pelas provas colhidas, que o réu é primário e tem bons antecedentes (fls. 33). Não fez prova o Ministério Público de que o réu se dedique ao crime ou faça parte de associação criminosa. Ao que consta dos autos, o réu apenas trazia consigo e guardava algumas porções de droga, conduta isolada e que possibilita prover-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive. Destarte, faz jus à redução em patamar máximo.

Cabe ser ressaltado, por outro lado, que, no momento da abordagem, o acusado não estava portando as munições para assegurar o sucesso do tráfico de drogas, de forma que não é possível reconhecer a conduta relacionada ao armamento como causa de aumento de pena da traficância.

Ao contrário, não há prova que as munições eram empregadas como meio para o tráfico, de forma que sua posse tem existência autônoma e desvinculada do tráfico das drogas.

Impõe-se a observação, outrossim, do cúmulo material entre o delito do artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Assim o é porquanto são delitos autônomos, praticados cada qual mediante uma ação diferente, que implica somatório das penas, com fundamento no artigo 69, do Código Penal.

Cabe lembrar, também que "A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta" (STJ, EREsp 1.856.980-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, julgado em 22/09/2021). No caso em apreço, conforme longamente explicado, houve apreensão de munições de arma de fogo aptas a efetuar disparos no mesmo imóvel em que o réu armazenava e guardava drogas de naturezas diversas, "o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade" (STJ, EREsp 1.856.980-SC).

Analizadas as teses da acusação e da defesa, conclui-se que o réu era, na data dos fatos, imputável, e tinha plena consciência de seus atos, não concorrendo nenhuma das causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que pudessem elidir sua responsabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa dúvida de que o réu mantinha munição de arma de fogo consigo e guardava drogas para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo responder penalmente pelos ilícitos praticados.

Passo, assim, à dosimetria das penas em obediência aos ditames do artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico de Nelson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza das drogas e suas quantidades não pesam em desfavor do réu, porquanto se trata de quantidade não excessiva que não justifica o aumento da pena-base. Anoto que, em peso líquido, foram apreendidos 24,3 gramas de entorpecentes (fls. 25/28).

A personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e

mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo

(nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comecinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, “estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade” (“A mentira do réu e a Dosimetria da Pena”, artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

“...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da “não verdade”, isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

“(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a

pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3ª Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1ª Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

"(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida" (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 33) e não há, nos autos, elementos para valorar sua conduta social. Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências são ordinárias, sendo neutras para o fim de fixação da pena. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico 'saúde pública', não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, à reprimenda mínima cominada em abstrato acresço 1/6, fixando a pena-base no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravantes ou atenuantes, mantenho inalterada a reprimenda.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aferidas. Impõe-se, por outro lado, o reconhecimento da causa de diminuição de pena consistente no tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, diminuindo a reprimenda em 2/3, alcançando o importe de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão , além de 194 dias-multa.

Do crime do artigo 12, da Lei 10.826/03:

Na fixação da pena-base, norteado pelo artigo 59, do Código Penal, tenho que a culpabilidade do réu não destoia da natureza do crime em questão. O réu não ostenta antecedentes criminais. Acerca da personalidade e da conduta social do réu, não há elementos para valorá-las. Isso porque pouco importa a real propriedade das munições localizadas no imóvel, porque o réu confessou que tinha ciência dos objetos e intencionalmente optou por mantê-los em seu imóvel. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não implicam exasperação da pena. Não há que se falar em comportamento da vítima no crime em questão.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, não observo a existência de causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Como explicitado na fundamentação, o caso dos autos exige a aplicação do cúmulo material de crimes, somando-se as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal. Cabe lembrar que os delitos são autônomos e atingem bens jurídicos distintos, o que implica somatório das penas.

Anote-se que, com relação ao tráfico de drogas, a pena foi de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, enquanto a posse irregular de munição de uso permitido rendeu à ré pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Tem-se, assim, um total de pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano de detenção e 204 dias-multa. Conforme disposição do artigo 69, parte final, Código Penal, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeiro aquela.

Tendo em conta a literal disposição do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, o regime adotado para o início do cumprimento de pena será o aberto.

Nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Isso porque a pena é inferior a 4 anos, os crimes não foram cometidos com violência, o réu admitiu a posse das drogas e das munições e não é reincidente. Além disso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos

e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Considerando que as reprimendas superam um ano, nos termos do artigo 44, § 2º, da Lei Penal, de rigor a substituição por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade, que serão fixados pelo Juízo da Execução, e limitação de finais de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Assente-se, outrossim, que a vítima é a sociedade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que, desde a concessão de habeas corpus (fls. 111 e 148), o acusado não esteve recluso por esse processo, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar. Não se pode perder de vista, ainda, que foi fixado regime inicial aberto para cumprimento de pena, a qual foi substituída por medidas restritivas de direitos.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos (fls. 137) em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse do réu.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Ricamar Gomes Duarte Júnior à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 1 ano de detenção e 204 dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e no artigo 12, da Lei 10.826/03, na forma do concurso material, iniciando-se o cumprimento em regime aberto, substituindo-as por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana. Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e o condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA